

1500228-78.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500228-78.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040540/2022 - 02º D.P.

PIRACICABA, 22973531 - 02º D.P. PIRACICABA, 628/22/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2040540 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GASPAS DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 07 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a), dr. Marcelo Luiz Borrasca Felisberto. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) GABRIEL GASPAS DA SILVA, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Renan Leandro Paes e João Pedro Alves Pereira.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Renan e João Pedro) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, GABRIEL GASPAS DA SILVA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta de 11h22min, na Rua Professora Lourdes Schmidt Furlan, nº 293, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, GABRIEL GASPAS DA SILVA, vulgo “Biel”, qualificado e indiciado às fls. 05/06 e 24/30, adquiriu e trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 54,7g (cinquenta e quatro gramas e sete decigramas) (item 1), 07 (sete) tubos de acrílico, 01 (um) tijolo e 46 (quarenta e seis) invólucros plásticos, todos contendo Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 547,2 (quinhentos e quarenta e sete gramas e dois decigramas) (item 2), 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 10,5 g (dez gramas e cinco decigramas) (item 3), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, GABRIEL - que de longa data se dedica a atividades criminosas - atuava no tráfico de drogas em conluio com indivíduos ainda não identificados.

Ocorre que, defronte uma casa em construção, foi surpreendido por policiais militares logo após receber um barril plástico das mãos de pessoa não identificada (Indivíduo pardo, magro e vestindo camiseta azul e que desembarcou de um veículo GM/Onix de cor preta) - que se evadiu com a aproximação policial.

Abordado e revistado, em sua posse foram encontrados R\$7,00 (sete reais).

No interior do barril que acabara de receber estavam as drogas acima descritas, acompanhadas de 1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de embalagens plásticas com fechamento tipo zip lock, 1.000 (mil) unidades vazias de eppendorfs e 04m (quatro) metros de etiquetas com imagem do traficante Pablo Escobar (fotos fls. 31/34). No imóvel em construção - com aparência de abandono - foi encontrada numa cômoda o documento de GABRIEL (fls. 24) e 01 (uma) balança de precisão, usualmente utilizada no fracionamento de entorpecentes. Informalmente, não assumiu a propriedade das drogas nem identificou ou indicou o paradeiro do indivíduo que lhe entregou os ilícitos.

Na delegacia, o denunciado ficou silente (fls. 05/06).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 10/12 e laudo pericial de constatação fls. 16/21) laudo definitivo de fls. 204-209.

Os eppendorfs e sacos plásticos sem uso era idênticos àqueles que embalavam as porções de cocaína e maconha.

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais, a visualização de movimentação característica de tráfico, a apreensão de cocaína e maconha em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, bem como a localização de vasto material de embalo, balança de precisão e etiquetas de identificação dos entorpecentes, é certo que o denunciado adquiriu e trazia consigo as drogas com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

João Pedro Alves Pereira - Policial Militar - narrou que estava em patrulhamento e viu o réu em contato com o condutor de um Onix preto. Viu o réu recebendo um tambor branco de uma pessoa de camiseta azul que saiu do banco do passageiro e pegou o tambor no banco de trás do carro. Eles empreenderam fuga quando se aproximou. O réu

ficou estático e foi abordado. Ele disse não saber quem eram as pessoas do carro nem o que tinha dentro do tambor. Ele disse que era reciclagem e que era catador de reciclagem. Ele estava tentando levar o tambor para dentro do terreno. Ele disse que era usado por usuários de drogas. Em uma cômoda na construção quebrada no terreno encontrou uma balança, um celular e o RG do réu. Ele disse que usava o local para usar drogas. No interior do barril tinham drogas e embalagens plásticas, eppendorfs. O local é conhecido por ser de tráfico de drogas. Não havia outras pessoas no imóvel. O réu estava conversando com as pessoas do carro antes de ser abordado.

No mesmo sentido, Renan Leandro Paes - Policial Militar.

O réu disse que tinha ido buscar uma droga na biqueira. Fazia dois dias que estava usando crack. O rapaz do carro preto entregou o tambor para "Lucão". Estava com sete reais para comprar drogas. O local é para uso de drogas. Quando "Lucão" ia pegar a droga no tambor para entregar ao interrogando, os policiais chegaram. "Lucão" correu para dentro da comunidade. Foi abordado. O rapaz que entregou o tambor fugiu com o carro. Morava no local, uma casa em construção. Permitiu aos policiais que entrassem na casa. O celular e a balança não funcionavam, os tinha achado na reciclagem.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Os policiais não tinham mesmo intenção de prejudicar o réu. Tivessem, bastaria dizer que o réu confessara os fatos (tráfico de drogas) quando da abordagem. Mas, ao contrário, disseram que o réu negou o conhecimento sobre as drogas no tambor. Mas essa negativa não prospera. As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

O réu foi surpreendido em contato com duas pessoas que ocupavam um veículo. Destas pessoas recebeu um tambor. Foi abordado. No tambor, drogas e materiais diversos para embalagens de entorpecentes. No terreno onde o réu intencionava entrar com o tambor, em uma cômoda existente em um imóvel deteriorado, os policiais encontraram uma balança de precisão e o RG do réu. Todos esses elementos trazem a certeza sobre a participação e envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer

excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 92/122): GABRIEL GASPAR DA SILVA ostenta maus antecedentes e reincidência -condenado por roubo circunstanciado nos autos n.º 034223-63.1999.8.26.0050 (fls. 94: t.j. em 28.12.2000, execução n.º 006697-36.2017.8.26.0521) e nos autos n.º 0022609-02.2011.8.26.0451 (fls. 96/98: t.j. em 14.11.2012), e por posse de drogas para uso pessoal nos autos n.º 0000429-91.2015.8.26.0599 (fls. 94/95: pena extinta em 16.07.2018, execução n.º 0008051-90.2016.8.26.0502).

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência, conforme gravação no Teams.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

GABRIEL GASPAR DA SILVA, vulgo "Biel", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta de 11h22, na Rua Professora Lourdes Schmidt Furlan, n.º 293, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, adquiriu e trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., maconha, com peso líquido de 54,7g (cinquenta e quatro gramas e sete decigramas) (item 1), 07 (sete) tubos de acrílico, 01 (um) tijolo e 46 (quarenta e seis) invólucros plásticos, todos contendo Cannabis Sativa L., maconha, com peso líquido de 547,2 (quinhentos e quarenta e sete gramas e dois decigramas) (item 2), 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) (item 3), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Gabriel – que de longa data se dedica a atividades criminosas – atuava no tráfico de drogas em conluio com indivíduos ainda não identificados.

Ocorre que, defronte uma casa em construção, foi surpreendido por policiais militares logo após receber um barril plástico das mãos de pessoa não identificada – que se evadiu com a aproximação policial.

Abordado e revistado, em sua posse foram encontrados R\$7,00 (sete reais). No interior do barril que acabara de receber estavam as drogas acima descritas, acompanhadas de 1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas) de embalagens plásticas com fechamento tipo zip lock, 1.000 (mil) unidades vazias de eppendorfs e 04m (quatro) metros de etiquetas com imagem do traficante Pablo Escobar (fotos fls. 31/34).

No imóvel em construção – com aparência de abandono – foi encontrada numa cômoda o documento de GABRIEL (fls. 24) e 01 (uma) balança de precisão, usualmente utilizada no fracionamento de entorpecentes.

Informalmente, não assumiu a propriedade das drogas nem identificou ou indicou o paradeiro do indivíduo que lhe entregou os ilícitos.

Na Delegacia, o réu ficou silente (fls. 05/06).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 10/12 e laudo pericial de constatação fls. 16/21).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais, a visualização de movimentação característica de tráfico, a apreensão de cocaína e maconha em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, bem como a localização de vasto material de embalo, balança de precisão e etiquetas de identificação dos entorpecentes, é certo que o denunciado adquiriu e trazia consigo as drogas com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 177), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 181/182). Notificado (fls. 188), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou inocência (fls. 192).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 193/195). O réu foi citado (fls. 239).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestam.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, no laudo de constatação de fls. 16/21, nas fotografias de fls. 31/34, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 204/206 e fls. 207/209, segundo os quais foi detectada a presença das substâncias Tretahidrocannabinol (THC), cocaína e tricloroetileno.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em Juízo, o réu disse que ficou 02 dias usando drogas, fumando crack, e, no dia dos fatos, foi buscar uma droga para consumir. Um rapaz desceu do Onix, tirou o tambor da parte de trás e o entregou para Lucão. Ia comprar drogas. ia usar a droga ali mesmo, onde várias pessoas fazem uso. Lucão chegou a pegar o tambor na mão e gritaram: "olha os bota", dizendo que os policiais estavam chegando. Lucão correu para dentro da comunidade e o rapaz que entregou o tambor entrou no carro e foi embora. Ficou parado. Os policiais abriram o tambor e acharam as drogas. Morava no local, um terreno com uma casa em construção. Os policiais pediram para entrar na sua casa e deixou. Eles encontraram seu RG, um celular que não funcionava e uma balança que não funcionava. Ia comprar a droga com Lucão. Passou 02 dias nessa casa. faz uso de cocaína e crack e é difícil ficar sem consumi-las. Tinha usado crack há 02 dias. Aquele local é conhecido como fumódromo. Não chegou a avistar a viatura, só viu quando eles estavam em cima. Não sabia o que havia dentro do tambor, só foi ver na Delegacia. Não teve conversa com o pessoal do carro. Estava conversando com Lucão, que saiu de dentro do mato. As pessoas do veículo estavam conversando com Lucão. Costumava dormir nessa casa, mas tem a casa da mãe, onde também fica. Tinha feito uso de cocaína, álcool e crack. Quando abordado, estava alterado. Foi condenado por posse de drogas, há mais de 20 anos.

A autoria foi confirmada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial militar Renan Leandro Paes relatou que estavam em patrulhamento e, de longe, visualizaram um carro parado. Um rapaz desembarcou do passageiro, abriu a porta de trás, pegou um tambor e entregou para o réu, que estava parado, conversando com os rapazes. Em dado momento, o veículo deixou o local rapidamente e o rapaz que tinha entregado o tambor, correu para dentro da comunidade. O réu, por sua vez, tentou colocar o tambor dentro de um terreno, onde havia uma construção. Abordaram apenas o réu. em revista pessoal, com o réu, no bolso, havia dinheiro. Dentro do tambor, havia drogas e materiais de embalo. Indagaram o réu e ele falou que a construção é usada pelos usuários de drogas, como ele, que ninguém morava ali. Ele autorizou a entrada na construção e encontraram cama, com colchão e roupa de cama, cômoda, bastante lixo no chão. Em cima da cômoda, havia uma balança de precisão. Em uma gaveta, havia um celular, que o réu disse não ser seu. Na outra gaveta, havia um RG do réu. o réu disse que não sabia de quem era o tambor e as drogas, que não morava no local. o réu falou que dentro do tambor, ele achava que tinha material de reciclagem. Não conseguiram abordar o rapaz que entregou o tambor ao réu e ele disse que não o conhecia. Notaram um certo diálogo entre o réu e o rapaz que fugiu. Não conhecia o réu. o local é ponto de venda e isso acaba atraindo muitos usuários. O tambor estava fechado. Ele é de tamanho médio. Não soube dizer se o diálogo entre o réu e o rapaz foi grande ou não. O réu tentou disfarçar e entrar no terreno com o tambor. O réu disse ser usuário de drogas. segundo o réu, a construção era para uso de drogas.

O também policial militar João Pedro Alves Pereira asseverou que estavam em patrulhamento, quando visualizaram um Onix preto e o réu estava perto do veículo. um indivíduo de camiseta azul desceu do passageiro, pegou um tambor no banco de trás e o entregou ao réu. Quando se aproximaram, o veículo e o passageiro de blusa azul empreenderam fuga. Apenas o réu foi abordado e disse que não sabia o que havia no tambor. Ele falou que era reciclagem. Questionaram o réu sobre o terreno vazio, tendo ele falado que era local onde as pessoas usavam drogas. entraram no terreno, onde havia uma construção quebrada e, no interior dela, havia alguns móveis velhos e lixo. Numa cômoda, encontraram o RG do réu, um celular e uma balança de precisão. O réu disse que não morava ali, que só ia ao local para usar drogas. dentro do tambor, havia material para embalo, lança-perfume, maconha, cocaína. O réu disse

não saber que havia drogas dentro do tambor. O local é de intenso tráfico de drogas. não havia mais pessoas no imóvel. O réu conversou com o rapaz que lhe entregou o tambor. Não conhecia o réu. não se recorda se o celular estava em funcionamento. O réu não mostrou reação. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas. o terreno fica perto da esquina, da entrada na comunidade. O réu estava na calçada. Depois que entregou o tambor ao réu, o rapaz olhou para cima, viu a viatura e já correu. Havia alguns móveis, mas não se recorda se tinha cama. A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, o réu alegou que não recebeu o tambor, que quem o recebeu foi Lucão, a pessoa que estava ali vendendo drogas. Acrescentou que não sabia o que tinha dentro do tambor e que Lucão correu para a comunidade e o rapaz do veículo nele ingressou novamente e fugiu.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram, em frente a uma construção abandonada, um veículo GM Onix preto, do qual desceu um indivíduo com um barril branco e o entregou para o réu, que estava na calçada. O indivíduo que estava entregando o citado tonel, ao ver a viatura, correu do local, ingressando na comunidade, não sendo possível sua captura. O veículo também fugiu do local, sem que anotassem sua placa. Já o réu, que recebeu o barril, foi abordado, quando estava tentando ingressar no terreno, com o tambor. Em seu bolso, foram localizados R\$ 7,00 e, no barril, havia 26 microtubos de cocaína, 01 tijolo de maconha, 42 vidros pequenos de lança-perfume, 53 porções de "skank" e 52 porções de maconha, um galão de 05 litros de lança-perfume, além de grande quantidade de embalagens vazias, mais de 1.500 microtubos para embalar cocaína, 02 quilos de embalagens plásticas pequenas, com zip, para embalar maconha, e inúmeras etiquetas com a imagem de Pablo Escobar. Questionado, o réu disse que as drogas não lhe pertenciam, que não sabia o que havia no barril, mas não relatou quem fossem os homens que lhe entregaram o tonel.

Assim, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, no sentido de que o tonel não estava em seu poder, e a dos policiais, que contaram terem presenciado o réu recebendo o tonel das mãos de ocupante de veículo não identificado.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Os policiais militares encontraram no interior da casa abandonada a cédula de identidade do réu, revelando que ali pernoitava e, portanto, o indivíduo que lhe entregou a droga tinha conhecimento de que ali o encontraria.

De outra banda, a chegada da viatura ocorreu quando a entrega da droga ocorria, tendo os policiais visto claramente que quem recebeu o tonel foi o réu e não terceiro. Ademais, os policiais disseram que quem saiu do carro e entregou o tonel foi quem fugiu para dentro da comunidade. Os policiais não indicaram que havia um terceiro, na mesma calçada que o réu, recebendo o tonel, pelo contrário, revelaram que foi o réu quem recebeu o tonel e tentou escondê-lo no terreno, antes da abordagem.

De outra banda, o tonel que o réu recebeu tem tamanho considerável, não havendo como se dizer que os policiais não pudessem visualizá-lo, ainda que de média distância.

Nesse sentido, entendo que a prova confirma que a droga foi localizada em poder do réu.

Ainda que assim não fosse, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos milicianos que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, diante do conjunto probatório angariado nos autos.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg.

Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

De outro lado, os policiais militares não conheciam o réu e, se quisessem prejudicá-lo, não teriam necessidade de utilização de tanta quantidade de droga, como a que foi apreendida.

Aduziu o réu que não sabia da existência de drogas no tonel, no entanto, se não soubesse que se tratava de produto ilícito, não teria tentado disfarçar, para evitar a abordagem.

Comprovada a posse da droga pelo réu, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que não tinha envolvimento com a droga apreendida. A prova, contudo, confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Os policiais militares presenciaram o momento em que o réu recebeu o tonel e o indivíduo que lhe entregou fugiu, ao perceber a aproximação da polícia. A fuga do entregador já revela que o conteúdo do tonel não era lícito.

Os policiais descreveram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e não como local de uso de entorpecentes.

No barril, havia quantidade e diversidade de drogas (26 microtubos roxos de cocaína, 01 tijolo de maconha, 42 vidros pequenos de lança-perfume, 05 litros de lança-perfume, 53 porções de skank, 52 porções de maconha) incompatíveis com a ideia de consumo próprio.

Além da droga, no tonel, foram encontrados petrechos para o embalo de mais entorpecente (mais de 1.500 microtubos para embalar cocaína, mais de 02 quilos de embalagens plásticas pequenas com zip, para embalar maconha, e inúmeras etiquetas com a imagem de Pablo Escobar).

No interior da residência abandonada, na frente da qual o réu foi abordado, foi possível constatar a existência de balança de precisão, equipamento para o

fracionamento da droga.

Assim, resta claro que a destinação da droga não era o consumo próprio, mas sim o consumo de terceiras pessoas.

Dessa forma, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a existência de farta quantidade de embalagens e etiquetas, tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câmb. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Arguiu o réu que não tinha conhecimento do que havia no interior do tonel. Ocorre, contudo, que ele estava numa casa abandonada, onde seus documentos foram encontrados, e onde os policiais encontraram uma balança de precisão.

De mais a mais, impossível que traficante de maior envergadura entregasse grande quantidade da sua mercadoria de trabalho ilícito para terceiro, sem a certeza de que o réu a guardaria ou a embalaria. O poderio econômico do entorpecente indica, pelo contrário, que o réu tinha elevado grau na hierarquia do crime, porque havia confiança em sua pessoa.

Nesse contexto, entendo que a alegação de ausência de conhecimento do conteúdo do tonel deve ser descartada.

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 94 - Processo n. 0034223-63.1999.8.26.0050; Certidão de fls. 94/95 - Processo n. 0000429-91.2015.8.26.0599; Certidão de fls. 96/98 - Processo n. 0022609-02.2011.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses

e 583 dias-multa.

Importante ressaltar que uma das condenações do réu (0000429-91.2015.8.26.0599) foi por porte de entorpecentes (artigo 28 da Lei nº 11.343/06) e que, em tese poderia gerar reincidência, em razão do tempo do término do cumprimento da pena, no entanto, devemos nos ater à possibilidade de reconhecimento da reincidência, ao caso concreto.

O primeiro entendimento do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 podia gerar reincidência, já que não houve a descriminalização do crime:

Informativo de Jurisprudência nº 0549, Período de 05 de novembro de 2014, Sexta Turma: DIREITO PENAL. REINCIDÊNCIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. A condenação por porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) transitada em julgado gera reincidência. Isso porque a referida conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada (abolitio criminis). Precedentes citados: HC 292.292-SP, Sexta Turma, DJe 25/6/2014; HC 266.827-SP, Sexta Turma, DJe 11/4/2014; e HC 194.921-SP, Quinta Turma, DJe 23/8/2013. HC 275.126-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/9/2014.

O mesmo órgão colegiado decidiu que é desproporcional a reincidência pela condenação em porte de entorpecentes, para o caso de tráfico de drogas:

Informativo nº 0632, Publicação 28 de setembro de 2018, Sexta Turma, processo REsp 1.672.654-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018, Tema: Tráfico de entorpecentes. Condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Caracterização da reincidência.

Desproporcionalidade, Destaque: É desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por fundamento a existência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio.

Acrescenta-se nas seguintes informações do Inteiro Teor: A questão em comento consiste em verificar se a condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio gera reincidência para o crime de tráfico de drogas. Este Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio (conduta que caracteriza ilícito penal) configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à falta de preenchimento do requisito legal relativo à primariedade. Ocorre, contudo, que a consideração de condenação anterior com fundamento no artigo 28 da Lei n.

11.343/2006 para fins de caracterização da reincidência viola o princípio constitucional da proporcionalidade. É que, como é cediço, a condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência pois o artigo 63 do Código Penal é expresso ao se referir à prática de novo crime. Assim, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Assim, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que as medidas previstas atualmente, que reconhecidamente não têm apresentado qualquer resultado prático em vista do crescente aumento do tráfico de drogas, tenho que o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de

reincidência.

Nesse contexto, não é possível o reconhecimento da reincidência em caso de tráfico de drogas, como no caso em comento, restando o acréscimo na primeira fase de aplicação da pena, como foi realizado.

O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado no caso concreto, é que o réu possui maus antecedentes. Além disso, a quantidade de drogas e petrechos apreendidos, todos que lhe foram entregues por terceira pessoa, indicam que ele integra organização criminosa que distribui entorpecentes, além de embalá-lo, utilizando-se de pessoas, cada qual com uma tarefa certa. Assim, o privilégio não pode ser reconhecido.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Ademais, o réu apresenta maus antecedentes, demonstrando que as penas anteriores não foram suficientes para afastá-lo da reincidência.

Pena final: reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR GABRIEL GASPAR DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena aplicada.

O réu está preso, e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença, pois seu estado empregatício (fls. 07 - desempregado) não o prende ao distrito da culpa, sendo a prisão garantia da aplicação da lei penal. Ademais, ele possui maus antecedentes, de forma que a prisão cautelar é necessária à garantia da ordem pública.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 176) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Informe-se a prolação desta sentença, nos autos do habeas corpus.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), saindo o(a)(s) defensor(a(es) intimado(a)(s) para apresentar as razões". Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):